

不作為犯に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 真正不作為犯と不真正不作為犯との違いは、刑罰法規そのものが構成要件要素として明文で不作為を規定しているか否かにある。
2. 作為義務を不真正不作為犯の成立要件とすることにより、結果の発生を回避し得る作為をしなかった複数の者の中から不作為犯の主体となり得ない者を除外することができる。
3. 不作為とは「一定の作為をしないこと」を意味するから、他人の住居内で居住者から退去要求を受けた場合になすべき「一定の作為」が「住居から退去すること」だとすると、「その住居内に居座ること」も「その住居内で財物を窃取すること」も不作為である。
4. 不真正不作為犯を認める見解に対しては、「無から有は生じない」から因果関係が認められないという批判があり得るが、期待された作為を行っていたら結果の発生が避けられたであろうという場合には因果関係が認められるとの反論が可能である。
5. 不真正不作為犯の成立要件としての作為義務を認めるためには不作為者が結果発生の原因となる先行行為を行えば足りるとする見解に対しては、故意又は過失によって人に傷害を与えた者が、その後殺意をもってその人を救助せず放置して死亡させた事案において、不作為による殺人罪が認められる範囲が狭くなり過ぎるとの批判が可能である。

No20	不作為犯	正答率
H22-2	正 解	59%

1 正しい

真正不作為犯とは、構成要件自体が不作為の形式で規定されている犯罪をいい、不真正不作為犯とは、作為の形式で定められている犯罪を不作為によって実現する犯罪をいう。両者の違いは、刑罰法規そのものが構成要件要素として明文で不作為を規定しているかどうかによる。

2 正しい

形式的に結果と因果関係の認められる不作為をすべて処罰すると、不真正不作為犯の処罰範囲は広がりすぎる。そこで、作為義務の有無によって、不作為犯の処罰範囲を限定してきた。そうであるとすれば、作為義務は、不作為犯の主体となり得ない者を除外する機能を有することになる。

3 正しい ★

刑法上の不作為は、単なる消極的な静止ではなく、法律上の作為義務に反して一定の身体運動をしないことを意味する。それゆえ、刑法上の不作為は、必ずしも身体の静止を意味するものではない。そのため、①住居に居座り、②その住居内で財物を窃取するといった作為があっても、退去を命ぜられたのに退去しない以上、不退去罪の構成要件との関係では不作為にあたる。

4 正しい

不真正不作為犯論において、かつて、不作為を「無」と解し、「無から有（結果）は生じない」として不作為の因果関係を否定した時代があったが、現在では規範的・価値的観点から不作為を「期待（予期）された行為（作為）をしないこと」と把握し、「期待された行為がなされたならば、結果の発生を防止し得たかどうか」という形態で不作為の因果関係（条件関係）を論ずるのが一般的である。

5 誤っている

結果発生の原因となる先行行為を行った者は、作為義務を負うとする見解がある。この見解は、故意又は過失の先行行為を行った者が、結果防止の作為の可能性があり結果を認容すれば、先行行為に係る過失犯が結果的加重犯が直ちに不作為による故意犯となることとなり、不真正不作為犯を不当に拡大することになるという批判がある。そうであるとすれば、殺人の原因となる傷害を故意又は過失によって負わせた者は、先行行為に基づき、被害者を救助する作為義務が広く認められ、その後殺意をもってその人を救助せず放置して死亡させた事案において、不作為による殺人罪が認められることとなる。したがって、本記述は、殺人罪が認められる範囲が狭くなりすぎるとして、誤っている。